



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 197/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

רוני פמילייר

רח' דוב הוז 19/21, כפר סבא
טל': 052-6145124

התובע

- נגד -

1. רפאל נעים

2. גאולה נעים

ע"י ב"כ עוה"ד יצחק קריטנסטיין
רח' סמילנסקי 4, נתניה 42432
טל': 09-8348924, פקס: 09-8621210

הנתבעים

פסק דין

1. עניינה של התביעה מתן צו הצהרתי שיורה כי השטח בו תפסו הנתבעים חזקה ייחודית הוא שטח משותף של הבית שברחוב האודם 24ב', בכפר יונה, הידוע כגוש 8124, חלקה 130 (להלן: "הבית"), ליתן צו עשה שיורה לנתבעים לסלק ידם מן הרכוש המשותף של הבית, וכן לפרק כל גדר ו/או מחסום ו/או כל בניה אחרת מכל סוג שהוא אותם בנו ברכוש המשותף של הבית, ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. הבית מורכב ממבנה אחד ומכיל 4 דירות. התובע הוא בעל זכויות חכירה בדירה בקומה השנייה של הבית. הנתבעים הם על פי הנטען, בעלי זכויות, בדירת הקרקע, המצויה מתחת לדירת התובע.
3. צו רישום הבית המשותף וכן התקנון המוסכם נרשמו ביום 1.12.11.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: במהלך חודש אפריל, 2010 בעת שערך התובע ביקור בדירתו, אותה הוא משכיר, מצא כי הנתבעים תפסו חזקה ייחודית בחלקים מהרכוש המשותף של הבית, תוך שינוי המבנה המיועד למתקן אשפה המשמש את דירת התובע והריסת אחד מקירותיו; הנתבעים גידרו את השטח בו תפסו חזקה ייחודית וכן ריצפו אותו ברצפת פרקט מעץ, כך שהפכו שטח זה לחלק מחצר הצמודה להם; בפעולות אלה נמנע מן התובע השימוש בשטח המשותף, וכן נמנעת ממנו הגישה למתקני החשמל של דירתו המצויים באותו השטח; בבדיקה שנערכה ע"י מפקח בניה מטעם הועדה לתכנון ובניה "שרונים" נמצא כי עבודות הבנייה נעשו שלא בהיתר, והנתבעים נדרשו להסדיר את המצב; פעולתם של הנתבעים נעשתה בלא שהתקבלה הסכמת התובעים לכך.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: התובע הגיש תביעה זוהה בעילותיה ובסעדיה אשר נדחתה בבית משפט השלום בנתניה במסגרת ת"א 54477-08-10, ומשכך יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 197/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

לדחות תביעה זו על הסף מחמת מעשה בית דין; למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות ליתן סעד של הריסה, ומשכך דין התביעה להידחות על הסף אף בהעדר סמכות עניינית. דין התביעה להידחות אף לגופה מהטעמים הבאים: 3 מתוך 4 בעלי דירות בבית נתנו הסכמתם לפעולות אותן ביצעו הנתבעים ברכוש המשותף; לא נמנעת מן התובע זכות גישה למתקן כלשהו, ואין כל מניעה לשימוש ברכוש המשותף של הבית; המצב בשטח כפי שהיה עובר לצו רישום הבית המשותף אינו תואם את הרישום, ומשכך יש להתעלם מצו רישום הבית המשותף וכן מהתקנון המוסכם שלא הובאו כלל לידיעת מי מהנתבעים; השימוש אותו עושים הנתבעים הוא שימוש סביר ברכוש המשותף; מאחר והתובע אינו מתגורר בדירה אין לו כל זכות לטעון כי נמנע ממנו השימוש ברכוש המשותף.

דיון והכרעה

טענות מקדמיות

6. לצורך ביסוס הטענה בדבר מעשה בית דין הפנו הנתבעים לת"א 54477-08-10. ואולם, עיון בפסק הדין אליו הפנו הנתבעים מעלה כי כב' השופט עוז ניר נאוי קבע באותו פסק הדין כי הוא אינו "מכריע בשאלת השטחים המשותפים, וממילא לא יהא בכך כדי למנוע מן התובע להגיש עתירה עתידית בעניין זה לאחר רישום הבית המשותף" (הדגשה שלי א.ש.). יוצא איפוא, כי אין בפסק דין זה כדי להוות מעשה בית דין, ואני דוחה את טענת הנתבעים בהקשר זה.

7. לא מצאתי גם לקבל את הטענה ולפיה המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות ליתן סעד של הריסה. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין ליתן סעד של הריסה נגזרת מזכותם של בעלי דירות הקבועה בחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), לכך שלא תבוצע פגיעה ברכוש המשותף מבלי שנתקבלה על כך הסכמה בהיקף הקבוע בחוק האמור, לפי העניין. בע"א 768/80, יוסף לחם נ' אליהו פומרנץ, לה(3), 527 נפסק כי מאחר והמפקח על רישום מקרקעין היה מוסמך לדון בסכסוך שהובא בפניו, הרי שעל פי הוראת סעיף 34 לחוק בתי המשפט {נוסח משולב}, תשמ"ד - 1984, הוא היה מוסמך ליתן סעד של הריסה. ראה גם ת.א. (י-ם), נציגות הבית המשותף נ' ריבלין (פורסם בנבו).

עתה אדרש לטענות הצדדים גופן:

8. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 197/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

9. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע כדלקמן:
- "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".
10. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.
11. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850:
- "... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם".
12. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שאין בו משום תפיסת חזקה ייחודית, והוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277: "שימוש ברכוש המשותף יחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים". עניין זה הינו פועל יוצא של ס' 31 (א) (1) לחוק המקרקעין הקובע כי " (א) באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים - להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".
13. סעיף 3.2 לתקנון המוסכם החל על הבית, אוסר אף הוא עשיית שימוש ברכוש המשותף אשר יש בו כדי להפריע או למנוע מבעלי דירות בבית שימוש והנאה מהרכוש המשותף, וזוהי לשונו:
- "כל אחד מבעלי הדירות בבית לא יעשה כל שימוש שהוא בדירה ו/או ברכוש המשותף באופן שיפריע ו/או ימנע בכל אופן שהוא שימוש והנאה סבירים ברכוש המשותף וביתר הדירות בבית על ידי בעלי הזכויות בהם ו/או מחזיקיהם..".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 197/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

14. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום".

ראה גם 302/63, רייס נ' לוטר קופף ואח', פ"ד יח(3), 309, 315: "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשין לב לעובדה שיש לו שכן".

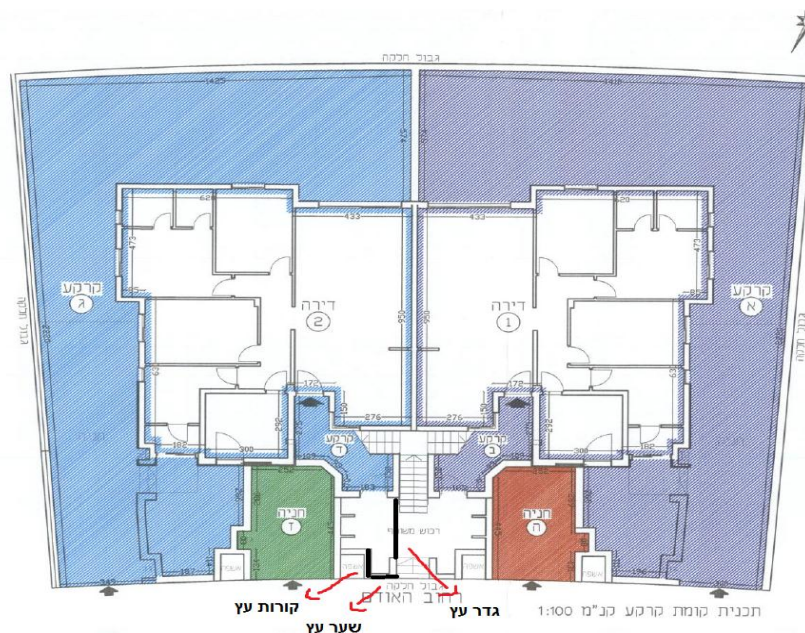
מן הכלל אל הפרט

15. התובע הציג חוות דעת של המודד ליבוביץ אשר קבע בחוות דעתו כדלקמן: "מצאתי כי בעל דירה מס' 2 (הנתבעים הוספה שלי א.ש.) השתלט על חלק מהרכוש המשותף, בשטח של 9.24 מ"ר, ע"י בניית גדר עץ ושער מעץ". חוות דעתו של המומחה לא נסתרה.

16. הנתבעת 1 הודתה בעדותה כי השטח שבמחלוקת נכלל ברכוש המשותף של הבית (ראה פרוטוקול מיום 26.12.13, עמ' 10 שורות 31-32, וכן עמ' 11, שורה 1).

17. הנה כי כן, הוכח כי השטח שבמחלוקת מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית.

18. ביום 30.9.03 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענותיהם. אציג את רשמיי על גבי המקטע הרלבנטי מתשריט הבית המשותף (להלן: "התשריט"). יודגש כי התשריט מובא לצורך המחשה בלבד (ראה גם תמונה המתארת את המצב בשטח – ת'1):





**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 197/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

א. הבית מכיל 4 דירות. דירת התובע בקומה השנייה. דירת הנתבעים בקומת הקרקע ומתחת לדירת התובע. כעולה מהתשריט, דירת הנתבעים מסומנת כיחידה 2, לה צמודה קרקע המסומנת באותיות ג' ו – ד' בצבע כחול, וכן חניה המסומנת באות ז' בצבע ירוק (ראה לעיל).

ב. ראיתי כי נבנתה גדר עץ וכן שער כניסה מעץ על השטח המשותף, כמסומן בתשריט לעיל.

ג. על גבי הקיר החיצוני של המבנה המשמש כפח אשפה מותקנים קורות עץ, כמסומן בתשריט לעיל.

ה. כתוצאה מהבנייה הנ"ל נתחמה חצר שבין הגדר לחניה, כשהכניסה לתוכה היא באמצעות שער עץ, כמסומן בתשריט.

ו. בחצר שנתחמה מותקן פילר חשמל המשמש את דירת התובע. התרשמתי כי נוכח הגידור כמפורט לעיל, לא מתאפשר מעבר ישיר לפילר החשמל, ועל התובע להיכנס דרך שער הכניסה בעוד שבהתאם לתשריט הבית המשותף קיימת כניסה ישירה ופתוחה לשטח זה.

ז. לא מתאפשר מעבר ישיר למבנה המשמש פח האשפה בעוד שבהתאם לתשריט הבית המשותף קיים מעבר ישיר למבנה זה.

ז. החצר שנחתמה מרוצפת בפרקט מעץ.

19. ממכלול הראיות שהובאו בפני ואשר פורטו לעיל, ומהתרשמותי בעת ביקורי, ובהתחשב באופן ובמיקום בו נבנו הגדר, שער הכניסה והפרקט, ובשימוש שעושים הנתבעים בשטח המשותף, התרשמתי כי השטח המשותף נחזה להיות חצר פרטית של הנתבעים המשמשת אותם באופן קבוע, והיא כשטח שלנתבעים חזקה ייחודית בו, בבחינת הצמדת השטח המשותף לדירתם. כן התרשמתי כי מבנה פח האשפה נחזה להיות בתוך החצר המשמשת, כאמור, באופן ייחודי את הנתבעים. מראית העין במקרה הזה היא חזות הכל. גם אם הנתבעים אינם תובעים לעצמם זכות שימוש בלעדית בחצר, כפי שאכן נטען בפני, ואף אם קיימת בפועל גישה לתוך שטח זה, יש להניח כי שימוש כזה לא ייעשה על ידי בעלי הדירות האחרים בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר.

20. אין חולק כי הסכמת התובע לא ניתנה לנתבעים, ודי לי בכך כדי לקבוע כי עשיית שימוש ייחודי זה בשטח המשותף, בדומה להצמדה לא תיתכן ללא הסכמתם.

21. לאור הפסיקה שהובאה לעיל, ובהינתן שהשטח שתחמו הנתבעים יוצר מראה ורושם של שטח אשר בחזקתם הבלעדית של הנתבעים, ברי כי שימוש זה שעושים הנתבעים באותו שטח משותף אינו עולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף. בנוסף, ומאותו הטעם יש לראות בשימוש ייחודי זה משום שימוש אשר הינו מנוגד לסעיף 3.2 לתקנון המוסכם החל על הבית.

22. לטענת הנתבעים הבנייה כמפורט לעיל, הייתה קיימת בשטח עוד טרם שנרשם הבית כבית משותף, ומשכך היא גוברת על צו רישום הבית המשותף ועל הוראות התקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 197/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

המוסכם החל על הבית. אין בידי לקבל טענה זו. הנתבעים לא הצביעו על כל זכות שבדין לביצוע הבניה. הנתבעת 2 הודתה בעדותה כי לא כך קיבלה את דירתה מהקבלן (ראה פרוטוקול מיום 26.12.12, עמ' 11, שורות 18-19: "ש. האם כך קיבלת את הנכס מהקבלן? ת. לא.."). העובדה כי הבניה הייתה קיימת עוד טרם רישומו של הבית המשותף אינה יוצרת את הזכות לקיומה.

23. משנרשם הבית המשותף, כפי שנרשם, הרי שהרישום מהווה ראיה חותכת לתוכנו. (ראה סעיף 125(א) לחוק המקרקעין), ומשכך על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ הדין על פי הרישום הקיים. ראה לעניין זה רע"א 587/83, וועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, פ"ד לח (4), 487. ראה גם ה"פ 30321-12-10, קדוש ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה ואח', (פורסם בנבו). ככל שקיימות לנתבעים טענות כנגד נכונות הרישום אזי אין מקומן של טענות אלו להתברר לפניי היות ובשאלת הבעלות במקרקעין קמה סמכות לבית המשפט המחוזי.

24. אציין גם כי מצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי אין לאפשר לתובע להגיש תביעתו מהטעם שאינו מתגורר בנכס. העובדה שהתובע אינו מתגורר בדירה אינה מעלה ואינה מורידה, ובוודאי שאין בה כדי לגרוע מזכויותיו הקנייניות בדירה אשר אין חולק כי היא בבעלותו.

25. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר בתוך 60 ימים מהיום, על חשבונם, את הבניה הקיימת על גבי הרכוש המשותף של הבית, ולהשיב המצב כפי שהוא בהתאם לתשריט הבית המשותף. הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, סך של 633 ₪ עבור החזר אגרת התביעה, סך של 2,340 ₪ עבור החזר שכר טרחת חוות דעת המומחה שהוגשה מטעם התובע, וכן סך של 750 ₪ עבור שכר בטלת התובע. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, זח' באב תשע"ד, 04 באוגוסט 2014. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה